

1502570-06.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502570-06.2021.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2248626/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 14685929 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 3813/21/506

- DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2248626 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Vítima:

PATRICIA DA SILVA PEREIRA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

14/02/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 14 de fevereiro de 2022, às 13h, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Ederson Rodrigo Alves, apresentado para a teleconferência pela Penitenciária de Martinópolis, nas dependências daquela unidade, seu advogado, Dr. Nelson Vallim Fischer, OAB/SP 119.706, e a vítima

Patrícia da Silva Pereira. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao interrogatório do acusado, a oitiva da vítima e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. Ao final, pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Ederson Rodrigo Alves, vulgo "Gagá", qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inc. I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal. Narrou que no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 15h06m, na Rua Orozimbo Leão de Carvalho, Vila Adileta, nesta cidade e Comarca, Ederson, em concurso de propósitos e identidade de desígnio com indivíduo não identificado, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, bens de valor pertencentes a Patrícia da Silva Pereira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo se apurou, Ederson e seu comparsa não identificado, numa moto CG, de cor aparentemente gasta, o piloto aproximou-se da vítima e o garupa sacou uma arma e anunciou o roubo, exigindo a bolsa e aparelho celular da ofendida; Patrícia e seus sobrinhos correram pedindo por socorro, o denunciado seu parceiro evadiram-se do local; a vítima reconheceu o acusado. A denúncia foi recebida em 03/12/2021 (fls.67/70). Citado, o réu apresentou defesa (fls.90/93). Nesta data foram ouvidas a vítima e interrogado o réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação do réu. Sustentou que: a vítima contou acerca da tentativa de roubo e reconheceu o réu com imparcialidade, sem qualquer sombra de dúvidas, como aquele que estava na garupa e exerceu a grave ameaça; o roubo apenas não se consumou porque ela e sobrinhos conseguiram correr, o que fez com que o réu e comparsa não conseguirem subtrair bens de valor; a vítima reiterou tudo que havia dito na fase policial; a versão do réu ficou isolada, não providenciou a oitiva de sua ex-mulher e não é crível que fosse perseguido pelo Delegado; o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente específico; há agravante do crime cometido durante período de pandemia; há duas causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes; deve ser fixado o regime inicial fechado e ser mantida a prisão. A douda Defesa pleiteou a absolvição, pois o depoimento foi insuficiente com relação à cor do capacete e à tatuagem nos braços; deveria ter sido feito reconhecimento presencial em Juízo; a vítima não sofreu prejuízo e o crime ficou na esfera da tentativa; o réu negou a autoria. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente. A materialidade do delito de roubo foi provada pelo boletim de ocorrência e auto de reconhecimento de pessoa (fls.06/07). A autoria do crime é certa e atribuída ao acusado, conforme se extrai dos autos de reconhecimento e dos relatos colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Ederson negou o crime, falou que nesse dia estava no balneário de Florínea com a esposa e filho. Negou conhecer a vítima Patrícia, ela pode ter sido enganada no reconhecimento. Relatou que foi o Delegado Marcelo que lhe incluiu nesse boletim de ocorrência, falaram que todos os BOs de roubo de moto iam colocar contra o depoente. Mencionou que ele ficou bravo porque estava ficando com a sobrinha dele. Disse que ainda tem contato com a esposa Cláudia. Declarou que já foi condenado por dois assaltos. Narrou que na época dos fatos tinha acabado de sair da cadeia e trabalhava como pintor e ganhava R\$ 120. A vítima Patrícia afirmou que caminhava com seus sobrinhos quando foram abordados por uma Titanzinha vermelha, os dois indivíduos pararam a moto e pediram para passar bolsa e celular, a depoente pediu para as crianças correrem. Relatou que o que estava na garupa levantou camiseta, estava com arma e a sacou. Mencionou que correram e como gritaram na rua os dois saíram. Disse que eles tentaram puxar a bolsa, mas não conseguiram. Contou que reconheceu na delegacia o que estava na Delegacia, acredita que ele era o que

estava na garupa e foi quem teve mais visão. Frisou que teve certeza no reconhecimento dele por causa da tatuagem, rosto, cor, tipo físico, o jeito. Informou que não se lembra ao certo do que era a tatuagem, mas viu exatamente naquele ponto, era moreno. Falou que apontou o garupa, na delegacia deu para reconhecer muito bem, os olhos castanhos, tipo do rosto, o capacete estava aberto, também pelo jeito, era magro. Narrou que no dia fez a descrição deles e outro dia aconteceu o reconhecimento na delegacia. Negou se lembrar se a pessoa tinha tatuagem no braço, lembra na perna. Esclareceu que não se fixou na cor do capacete, recorda da cor da moto. Pois bem. A vítima narrou em Juízo que foi abordada por duas pessoas numa moto, as quais deram voz de assalto. Ela contou que o garupa lhe apontou a arma e tentou tomar a bolsa, ela gritou e correu junto com os sobrinhos dela. Na sequência os assaltantes fugiram sem levar nada. Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte das vítimas que legitimasse a posse de seus bens pelo réu. A inexistência de autorização torna certo que tentou possuir “coisa alheia móvel”, elemento essencial do tipo penal e detinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. O réu foi reconhecido pela vítima como a pessoa que tentou lhe assaltar. Patrícia reconheceu o réu na Delegacia por várias características, como tatuagem, rosto, cor da pele, tipo físico, cor dos olhos e peso corporal. A jurisprudência majoritária defende que em crimes deste jaez, em regra cometidos à revelia de terceiros, a palavra segura da vítima ao fornecer elementos de identificação do criminoso é de suma valia, pois manteve contato direto e pessoal com ele. Nesse sentido, citem-se os julgados: Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los (Revista dos Tribunais, vol.606, p.357, rel. Costa Manso, destaquei). A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores (JTACrSP, vol.100, p.250, rel. Almeida Braga, destaquei). Embora a combativa Defesa tenha questionado a ausência de reconhecimento pessoal em Juízo, noto que nenhuma das partes solicitou esta providência durante a audiência e este Juízo sempre defere o ato quando solicitado. De qualquer forma não vislumbro prejuízo, pois o relato em Juízo indica que a vítima reconheceu Ederson por diversos elementos característicos. A vítima prestou relato convincente todas as vezes em que foi ouvida. Por outro lado, a versão do réu, de que estava no balneário de Florínea com sua ex-esposa, não foi comprovada por nenhuma testemunha. Poderia a combativa Defesa ter providenciado a oitiva de alguma pessoa que tivesse visto Ederson em Florínea no dia dos fatos, mas não fez qualquer prova. No mais, o réu não apresentou motivo concreto para uma vítima que sequer lhe conhecia lhe acusar injustamente. Ademais, o réu tem relevante histórico de envolvimento em crimes patrimoniais, notadamente pela prática de roubo, crime pelo qual foi condenado três vezes (fls.40/44). Embora o passado do agente não sirva como prova cabal de que praticou a conduta, nada impede que sirva como indício de que é mais um exemplo de seu comportamento habitual.

Pela dinâmica relatada em Juízo pela vítima extrai-se que a tentativa de roubo foi praticada mediante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Não resta dúvida acerca da caracterização da grave ameaça, inerente ao presente tipo penal. Apesar de não ter sido periciada a arma de fogo, tal circunstância não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena, como se observa pelo seguinte julgado do E. Supremo Tribunal Federal: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPAROS. ORDEM DENEGADA. 1. O roubo qualificado dispensa a apreensão da arma de fogo no afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 05.06.2009). 2. In casu: a) os pacientes, mediante violência e grave

ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram diversos bens da vítima, um moto taxista, dentre os quais, o capacete que portava, dinheiro e documentos; b) a vítima foi atacada com socos e chutes, e com uma arma de fogo, utilizada para agredi-la fisicamente e ameaçá-la durante o tempo em que durou a ação delituosa. 3. É cediço na Corte que: "ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (Precedentes de ambas as Turmas: HC 104368/RS, Rel. Ministro AYRES BRITTO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03.09.2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 11.06.2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16.04.2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01.02.2011, DJe 09.03.2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23.11.2010, DJe 01.02.2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23.11.2010, DJe 01.02.2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, SEGUNDA TURMA, DJe 26.06.2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 04.12.2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.12.2010, DJe 08.02.2011).

4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 103.910/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz Fux, j. 08.11.2011, unânime, DJe 05.12.2011, destaquei). É o caso de reconhecer que o crime se deu na modalidade tentada. O réu deu voz de assalto à vítima, apontou a arma a ela e tentou puxar a bolsa, mas não conseguiu. A vítima gritou por socorro e correu, o que levou o réu e seu comparsa a fugir do local sem consumir a prática do furto. O acervo informativo trouxe elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo. Portanto, havendo provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva, presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação dos requeridos nas penas do crime de roubo é medida que se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício dos réus não militam quaisquer justificativas ou dirimentes: A culpabilidade, ora entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de elevada intensidade. O réu é multireincidente e já ostenta cinco condenações transitadas em julgado (fls.40/44), o que justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Segundo a doutrina, (...) "nada impede que o agente possua várias condenações anteriores, sendo lícito ao magistrado considerar uma delas para efeito de gerar reincidência e as demais, como maus antecedentes. Inexiste, nesta hipótese, bis in idem, pois são elementos geradores diversos". (Nucci, Guilherme de Souza, Individualização da pena, 6ª ed., rev.. atual e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2014, p.167). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também adota entendimento de que "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016, destaquei). Não há indicativo acerca da personalidade do réu e conduta social. Os motivos do crime foram inerentes ao tipo, não o prejudicando. As circunstâncias do crime são normais. O comportamento da ofendida não levou o réu à prática deste delito. As consequências do crime não foram graves. Na primeira fase, após

considerar tais elementos, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase verifico que ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que “o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente” (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto noto que Ederson é multireincidente, pois já foi condenado definitivamente por 5 vezes, sendo pelo menos 3 por roubo, e persistiu na senda do mesmo crime. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração rigorosa da pena em casos como este, pois tal prática demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminosa. No final, o acórdão ficou ementado da seguinte forma: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amalhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079 - AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18.03.2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 169738/SC, 1ª Turma, Rel. Alexandre de Moraes. j. 07.06.2019, maioria, DJe 14.06.2019). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica. Confira-se: “A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (STJ, HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/02/2014)”. Pelo julgado acima citado que o patamar de 2/3 foi aceito pela Suprema Corte para uma pessoa que tinha 7 condenações, duas a mais que o réu destes autos. Assim, é caso de agravar em 1/2 (metade) pela multireincidência. Reconheço também a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus, conforme reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020, o que justifica incremento de 1/6 (um sexto). Entendo que há uma relação com o crime de roubo, pois a pandemia refletiu no fluxo de pessoas na rua e a própria vigilância policial. Esta agravante já foi aplicada em no julgamento de um traficante pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação.

Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública" (STJ, HC 584871/SP, Min, Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei). Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, "se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Portanto, levando em conta estas duas agravantes majoro as penas em 2/3 (dois terços) e as fixo provisoriamente em: em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Na terceira fase não há causas de diminuição da pena. Considerando o concurso de agentes majoro a pena em 1/3 (um terço) e fixo a pena em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. Ainda nesta fase é caso de efetuar novo aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. A Lei nº 13.654, de 2018, passou a tipificar o emprego de arma de fogo no §2º-A do art. 157, adotando tratamento mais gravoso para esta qualificadora, ao cominar aumento de pena à fração de 2/3. Tal dispositivo veio recrudescer a situação daquele que pratica gravíssimo delito de roubo valendo-se de arma de fogo na empreitada criminosa. Tem-se que as aventadas qualificadoras se encontram, após a alteração legislativa, previstas em parágrafos distintos e estabelecem graus de aumento diversos: enquanto à comparsaria comina-se aumento de 1/3 até a metade, ao uso de arma de fogo o aumento se dá, diga-se novamente, à fração fixa de 2/3. Com alteração legislativa, necessário que sejam tais majorantes valoradas separadamente, a afastar a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em casos como o presente. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal preconiza, sob o ângulo literal, apenas uma faculdade de o julgador, na hipótese de concurso entre causas de aumento e entre causas de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição. Não se trata de obrigatoriedade, mas de mera faculdade disposta ao julgador. Segundo o ilustre Professor Edilson Mougenot Bonfim: "Nos termos do parágrafo único do artigo 68, do CP, o juiz pode limitar-se à aplicação da causa que mais aumente, desprezando as demais (trata-se de faculdade do juiz)" (BONFIM, Edilson Mougenot, Fernando Capez, Direito Penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 728). Entendo que o delito de roubo praticado por mais de um agente e com emprego de arma de fogo merece reprimenda mais severa do que, por exemplo, o delito de roubo cometido apenas com a majorante do emprego de arma de fogo. Não fosse uma mera faculdade do juiz a disposição contida no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estaríamos destinando tratamento igual a situações desiguais e violando o princípio constitucional da individualização das penas que preconiza a necessidade de distinguir condutas ilícitas e pessoas condenadas pela prática de infrações penais. Nesse sentido é a lição de André Estefam: "(...) todas as causas, sejam elas de aumento ou redução, que estiverem contidas na Parte Geral serão de incidência obrigatória. Com relação às da Parte Especial, serão obrigatórias quando houver só uma causa de aumento e/ou uma de redução. Existindo mais de uma causa da mesma natureza na Parte Especial, faculta-se ao magistrado aplicar todas ou somente uma delas, escolhendo sempre o maior aumento ou a maior redução". (ESTEFAM, André, Direito Penal: Parte Geral. 7 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 447-448). A jurisprudência corrobora a possibilidade de dupla incidência de causas de aumento de pena: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE "FOTOGRAFAR" MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA

NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...) (STF. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. em 19/08/2014, DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014, destaquei). PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM'S. ROUBO MAJORADO, RECEPÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 157 §2º, II E § 2º-A, I E 180 DO CP E 14 DA LEI 10.826/03. ANÁLISE EM ASSENTADA ÚNICA, ANTE A CONVERGÊNCIA DOS ARGUMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS A PARTIR DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDOS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS E PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE ARRIMADA EM UM VETOR INIDÔNEO (CONSEQUÊNCIAS). DESNECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO, DADA A SUBSISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS, CUJO RESULTADO FINAL NÃO DESBORDA DA DIRETRIZ DE 1/8 SUGERIDA PELO STJ. POSSIBILIDADE DE CÚMULO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO, SOBRETUDO COM A EDIÇÃO DA LEI 13.654/18. DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME A SEREM EXAMINADAS NO JUÍZO EXECUTÓRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJRN. Apelação Criminal nº 2019.001632-4, Relator: Des. Saraiva Sobrinho. Julg. 05/11/2019, destaquei). Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços) pela presença da majorante do emprego de arma de fogo e torno a pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Por fim, a diminuição relativa à tentativa (art. 14, inc. II, do Código Penal) deve atender ao critério do caminho já percorrido pelo agente na prática do delito (iter criminis), ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito menor será o abatimento. Levando-se em conta os atos executórios praticados (dar voz de assalto e puxar a bolsa da vítima) e a proximidade da consumação, deve a pena ser diminuída em 1/2 (metade). Assim, fixo definitivamente a pena em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual mínimo legal, em face da renda apurada na ocasião do interrogatório e do salário-mínimo vigente quando dos fatos, valor que deverá ser atualizado monetariamente até o pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, ante o montante da pena e a grave ameaça exercida. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado, considerando a reincidência e o total da pena. Por fim, recentemente foi publicada a Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º traz o § 2º ao art. 387 do CPP: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do

legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Considerando a pena acima fixada, o réu somente faria jus à progressão de regime para o semiaberto após o cumprimento de 30% da pena, o que não ocorreu. Assim, apesar da detração ora realizada, o regime inicial de cumprimento da pena restante será o fechado. Diante do exposto, com amparo no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação para: a) CONDENAR o réu Ederson Rodrigo Alves, à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias multa, cada qual mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois lhes concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar e praticou

crime gravíssimo, com concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e a jurisprudência que adoto como razão de decidir, in verbis: "Criminal. RHC. Formação de quadrilha. Receiptação qualificada. Adulteração de sinal de veículo automotor. Apelação em liberdade. Réu preso durante toda a instrução do processo. Efeito da condenação. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Regime prisional. Argumentos não apreciados pelo tribunal a quo. Supressão de instância. Incompetência desta corte. Existência de recurso próprio. Impetração simultânea ou isolada. Possibilidade. Análise do mérito determinada ao tribunal a quo. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício. Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...) " (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei). Haja vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta ao Diretor do estabelecimento. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Confirmada a condenação, extraiam-se cópias do acórdão e certidão de trânsito em julgado, enviando-se à V.E.C. competente, para complementar a Guia de Recolhimento Provisória, tornando-a definitiva; 4) Comunique-se à ofendida sobre a decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 6) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 7) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 8) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuirá ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 9) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e

decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva". Em seguida, o(a)(s) Defensor(a)(es) e o(s)rêu(s) manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. 1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias. 2. Se não forem apresentadas razões no prazo determino à Serventia que intime o Advogado para apresentar as razões em 24 horas e, se não fizer, providencie a nomeação de outro Defensor e a comunicação do fato à OAB. 3. Após a apresentação das razões de recurso, o recorrido deve ser intimado para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 4. Arbitro honorários parciais à douda Defesa em 70% do respectivo item do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB. Expeça-se a certidão; 5. Expeça-se a guia de execução provisória e envie-se à VEC competente. 6. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta ao(s) sentenciado(s), anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 13 de fevereiro de 2038. Saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Eu, Antônio Celso Sanches, digitei.